

1503941-54.2022.8.26.0472

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... condenado duas vezes pela prática do tráfico de drogas em ponto de venda próximo ao local dos fatos, também no Jardim Anésia (cf. documentos às fls. 58/79). Assim, a localização do denunciado em conhecido ponto de tráfico na posse de considerável quantia em dinheiro, a grande quantidade e variedade de drogas localizadas no imóvel a ele atribuído no mandado de busca, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, . - Centro

CEP: 13660-017 - Porto Ferreira - SP

Telefone: (19) 3581-2201 - E-mail: portoferr2@tjsp.jus.br

1503941-54.2022.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503941-54.2022.8.26.0472

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JONATAS HENRIQUE DA SILVA SANTOS

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de JONATAS HENRIQUE DA SILVA SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06 afirmando que em 24 de agosto de 2022, por volta de 17h, na Estrada Velha de Descalvado, nº 820, Jardim Anésia, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, tinha em depósito, para fins de tráfico, 332 porções de "cocaína" com peso bruto de 576,0 gramas, 150 porções de "crack" com peso bruto de 61,0 gramas e 04 tabletes de "maconha" com peso bruto de 112,0 gramas.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "policiais civis se dirigiram ao endereço acima mencionado para dar cumprimento aos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva expedidos em desfavor do denunciado nos autos nº 1503714-64.2022.8.26.0472 - 2ª Vara Judicial de Porto Ferreira (fls. 07/09). Ao se aproximarem do local, os agentes públicos avistaram o denunciado em um conhecido ponto de venda de drogas situado na mesma na rua do endereço alvo das buscas, no que fizeram a abordagem dele para cumprimento do mandado de prisão. Realizada busca pessoal, foi localizada com JONATAS a quantia de R\$ 500,00 em notas diversas e um aparelho celular. Ato contínuo, os policiais civis se dirigiram para o local declinado no mandado de busca atribuído ao denunciado (Estrada Velha de Descalvado,

nº 820) e, na porta de entrada, já dentro do terreno no endereço alvo das buscas, perceberam que havia uma cavadeira com vestígios recentes de uso na terra, bem como resíduos de sacos plásticos comumente utilizados na embalagem de entorpecentes, o que chamou a atenção deles, razão pela qual procederam às buscas e lograram encontrar, debaixo de uma cuba de pia no chão, as drogas acima descritas. Registre-se, por oportuno, que quando adolescente o denunciado já havia sido condenado duas vezes pela prática do tráfico de drogas em ponto de venda próximo ao local dos fatos, também no Jardim Anésia (cf. documentos às fls. 58/79). Assim, a localização do denunciado em conhecido ponto de tráfico na posse de considerável quantia em dinheiro, a grande quantidade e variedade de drogas localizadas no imóvel a ele atribuído no mandado de busca, a disposição fracionada e o local onde elas estavam escondidas e, ainda, o histórico de traficância na mesma região demonstram, com segurança, que o denunciado tinha em depósito os entorpecentes com a finalidade de tráfico."

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu ritual legal, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico (finalidade da proteção penal) é a saúde pública.

No caso em exame, há prova da existência do crime e de sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 18/20), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), pelos laudos periciais (fls. 111/113, 114/116 e 197/199) que resultaram positivos para as drogas encontradas e, sobretudo, pela prova oral colhida. A autoria também é certa.

A testemunha de acusação, o policial civil Brizano Aparecido da Silva, na fase policial disse que "nesta data, na companhia de outros policiais civis desta Unidade, efetuaram diligências para dar cumprimento ao Mandado de Busca e apreensão referente ao Processo 1503714-64.2022.8.26.0472 expedido pela 2ª Vara do Foro de Descalvado, bem como para o cumprimento de mandado de prisão preventiva contra Jonatas Henrique da Silva Santos; que, durante a diligência Jonatas Henrique da Silva Santos foi abordado na mesma rua do endereço alvo das buscas, com outros indivíduos, num local conhecido como ponto de venda de drogas; que, efetuada a busca pessoal foram encontrados R\$ 500,00 (quinhentos Reais) em notas diversas com o Jonatas, bem como um aparelho celular da marca Motorola; que, em seguida a equipe seguiu para o endereço alvo das buscas - Estrada Velha de Descalvado, 820 - Jardim Anésia, nesta cidade; na porta de entrada, já dentro do terreno endereço alvo das buscas havia uma cavadeira com vestígios recentes de que a terra fora revirada, além de resíduos de sacos plásticos comumente utilizados para embalagem de drogas que chamaram a atenção; que, ao vasculhar o local foram localizadas, sob uma cuba de pia a quantia de 332 microtubos contendo pó branco semelhante a cocaína, sendo 90 pequenos e 242 grandes, além de 150 pedras de crack e 4 pedaços de erva esverdeada, todos fracionados, embalados e prontos para comércio; que, Jonatas foi questionado sobre aquelas drogas e negou ser proprietário, não informando a quem pertenciam; que, em vista dos fatos Jonatas foi conduzido a esta Delegacia para providências de praxe."Em juízo manteve sua versão. Entende que a droga era de Jonatas porque o acesso à droga só se dava pela entrada do imóvel onde ele reside

(explicou as dificuldades de acesso partindo de outros locais); a distância é inferior a dois metros. A bicicleta era da irmã de Jonatas. Não ficaram com dúvidas a respeito da relação das drogas com o imóvel onde Jonatas reside. Questionou Jonatas se ele era gerente de outro traficante, mas ele não quis falar. A testemunha de acusação, o policial civil Carlos Henrique Campos, na fase policial disse que "nesta data, na companhia de outros policiais civis desta Unidade, efetuaram diligências para dar cumprimento ao Mandado de Busca e apreensão referente ao Processo 1503714-64.2022.8.26.0472 expedido pela 2ª Vara do Foro de Descalvado, bem como para o cumprimento de mandado de prisão preventiva contra Jonatas Henrique da Silva Santos; que, durante a diligência Jonatas Henrique da Silva Santos foi abordado na mesma rua do endereço alvo das buscas, com outros indivíduos, num local conhecido como ponto de venda de drogas; que, efetuada a busca pessoal foram encontrados R\$ 500,00 (quinhentos Reais) em notas diversas com o Jonatas, bem como um aparelho celular da marca Motorola; que, em seguida a equipe seguiu para o endereço alvo das buscas, na Estrada Velha de Descalvado, 820 - Jardim Anésia, nesta cidade, sendo que na porta de entrada, já dentro do terreno endereço alvo das buscas, havia uma cavadeira com vestígios recentes de que a terra fora revirada, além de resíduos de sacos plásticos comumente utilizados para embalagem de drogas que chamaram a atenção; que, ao vasculhar o local o Investigador Brizano localizou sob uma cuba de pia a quantia de 332 microtubos contendo pó branco semelhante a cocaína, sendo 90 pequenos e 242 grandes, além de 150 pedras de crack e 4 pedaços de erva esverdeada, todos fracionados, embalados e prontos para comércio; que, Jonatas foi questionado sobre aquelas drogas e negou ser proprietário, não informando a quem pertenciam; que, em vista dos fatos Jonatas foi conduzido a esta Delegacia para providências de praxe." Em juízo manteve sua versão. Entendeu que a droga era de Jonatas porque havia próximo ali havia uma cavadeira e o local distava 1,5m da porta da sala; apontou também a existência de um triozinho; Jonatas estava em um ponto de venda de drogas no momento da abordagem portando R\$500,00 em seu bolso. No imóvel 820 estava a irmã dele e uma senhora; não há qualquer notícia do envolvimento delas com o tráfico. O local onde foi encontrada a droga tinha acesso para outros imóveis, mas ela estava muito próxima da casa dele.

JONATAS HENRIQUE DA SILVA SANTOS, em declarações perante a autoridade policial, disse que "nega que a droga apreendida seja de sua propriedade; que o interrogando não tem envolvimento com o tráfico; que sobre a droga apreendida o interrogando afirma que não lhe pertence; que o interrogando afirma que não mora no local onde foi achado o entorpecente; que a droga foi achado no número 820, sendo certo que o interrogando mora no 1220 da mesma rua; que deseja acrescentar onde sua mãe reside, há três casas, sendo que, o local onde foi localizada a droga é área de comum acesso a todas as casas; inclusive de outros vizinhos; que ninguém de sua família tem envolvimento com a traficância; que o interrogando foi abordado na rua por policiais civis e nada de ilícito foi achado em seu poder; que sobre o valor de R\$ 500,00 reais que estava em seu bolso, afirma que eram provenientes da venda de um aparelho celular hoje pela manhã; que o interrogando trabalha de ajudante de pintor; que não tem antecedentes criminais; que sobre a violência doméstica, informa que não desrespeitou medida protetiva; que JENIFER NATALIA está com raiva do interrogando por ciúmes uma vez que está separado e acabou se envolvendo com outras mulheres; que Jenifer inclusive está grávida do interrogando." Em juízo se disse inocente. Disse que não morava nesse local. Quem mora ali é sua mãe e sua família (nenhum deles é envolvido com o tráfico). Quando os policiais chegaram não estava em um ponto de venda de drogas; estava em frente a uma cervejaria, estava de passagem; estava indo para sua casa na Estrada Velha de Descalvado, 1220. Morava ali havia 5 meses. Dinheiro era objeto da venda de um celular. Estava com o dinheiro para pagar sua casa. Vendeu o celular para Jailson Santos. Ia almoçar na casa de sua mãe almoçar e jantar com frequência. Quando foi preso distava 3 quarteirões do número 820. Policiais foram no 1220, mas não encontraram nada. Na frente do número 820 tem um ponto de drogas. Está sendo acusado porque não declarou o nome do proprietário das drogas.

Embora tenha negado os fatos, a versão do acusado ficou deveras fracas dentro do contexto dos autos. A relação entre Jonatas e o imóvel já era apontada pelos policiais antes da busca e apreensão. Ademais, a proximidade da droga com este imóvel e a dificuldade de acesso a partir de outro imóvel demonstra que Jonatas tinha essas drogas em depósito.

Não há nulidade quanto à diligência de obtenção de provas vez tratar-se de serendipidade.

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Passo a dosar as penas.

Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima gera outra injustiça. Percebe-se que em alguns casos a qualificadora somente aumenta a pena máxima; é o que ocorre, a título de exemplo, com a lesão simples no âmbito da violência doméstica. Ora, calcular os aumentos tendo por parâmetro a pena mínima é ignorar o comando legal que deu especial gravidade ao delito cometido naquela situação específica.

Sem contar os casos em que o intervalo de pena é menor que a pena mínima (§3º do art. 302 da Lei 9.503/97, artigos 267, 270 e 273 do Código Penal, entre outros), quando a utilização somente desta causa considerável prejuízo ao réu.

As situações e razões aqui trazidas são suficientes para demonstrar que a fixação da pena na primeira fase levando em conta somente a pena mínima contraria a lei e o sistema de imposição de sanções por ela previsto.

Ora, como o legislador estabelece sempre um mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de modo que o procedimento mais adequado para perceber essa grandeza em sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento sobre o intervalo, adicionando a pena mínima.

É o que recentemente vem fazendo o STJ:

Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da basilar em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime.

STJ, AgRg no AREsp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

A gravidade concreta do delito, praticado por pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e preservar o pundonor que rege a caserna; bem como o modo de execução, tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral, justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que vai de 2 anos a 8 anos de reclusão.

STJ, AgRg no REsp 1678420/PA, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,

julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018.

Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto condenatório.

STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Quanto aos maus antecedentes, descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses, considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

Mantém-se a valoração negativa das vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, descabendo falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 6 anos.

STJ, HC 446462/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

É também a posição do Plenário do STF:

Ausente a alegada desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados na dosimetria das penas dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, sobretudo porque se tratam de delitos cujas objetividades jurídicas são distintas e que apresentam diferentes intervalos penais nos respectivos preceitos secundários.

AP 470 EDj-sétimos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 05/09/2013, DJe 10/10/2013.

Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização.

AP 470 EDj-vigésimos quartos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 28/08/2013, DJe 10/10/2013.

Aliás, em ações de competência originária das cortes superiores a dosimetria no intervalo da pena é uma constante.

Por exemplo, nos dois títulos penais condenatórios emitido pela Suprema Corte em 2019 (AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019, e AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020) nota-se claramente este procedimento (grifos nossos - diversos do original):

13.a.1) Quanto ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de três anos de reclusão e máxima de doze anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

13.b.1) Relativamente ao crime de empréstimo vedado (art. 17 da Lei 7.492/1986) (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de dois anos de reclusão e máxima de seis anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe

20/05/2019.

No juízo de individualização da pena à luz do caso concreto, anoto que a sanção cominada de forma abstrata ao crime de lavagem de dinheiro é de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, nos termos do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998. (...) fixo-lhe a pena-base, para cada delito de lavagem de dinheiro, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020.

A dosimetria foi adotada por unanimidade pelos dois colegiados, conforme extratos de ata.

Não diverge a Segunda Turma do Pretório Excelso. Na condenação em ação penal originária (AP 644/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 16/03/2018) assim se pronunciou:

(...) deve-se observar as penas originalmente cominadas, "reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa" (...) Considerando a particular gravidade das circunstâncias mencionadas, estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em sentido idêntico a Corte Especial do STJ (APn 327/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018):

Os fatos narrados ajustam-se aos elementos configuradores do delito de peculato-desvio (art. 312, 2ª parte do Código Penal). (...)

Portanto, diante destas três circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Assim, sopesadas tais circunstâncias e observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Observar no voto acima que o aumento na pena corporal é idêntico ao da pena de multa, caso se considere o intervalo das penas (30% dos intervalos).

Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Além de não haver respaldo legal, isso fere de morte o espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos do caso.

Não se há falar em tabelamento das reprimendas, nem mesmo em institucionalização da pena mínima.

TJSP, Apelação n. 0000142-53.2017.8.26.0472 , 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j. 23.08.2018.

Preambularmente, lembro que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base.

AP 996/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, DJe 08/02/2019.

Segundo o procedimento que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, merecerá a reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo.

Ora, isso é uma má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido

pela Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de reprovação e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juízes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juízes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das circunstâncias que da extensão com que são encontradas.

Não se nega, contudo, que alguns julgadores ainda se valem do antigo método da pena mínima e do tabelamento de aumentos. Todavia, agindo contra toda a jurisprudência dos tribunais superiores, é dever justificar a heterodoxia.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

A definição de quais substâncias são consideradas ilícitas se encontra na Portaria SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998 (ver artigo 66 da Lei 11.343/06) e nesta definição se incluem todas as previstas no Anexo I (ver, p. ex., REsp.

1.444.537/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016).

Portanto, em referência ao critério da natureza da droga, por constarem da Lista F do Anexo I (substâncias de uso proscrito, ou seja, proibidas sob quaisquer circunstâncias ou concentrações pela natureza intrinsecamente nociva que possuem), merecem valoração nesta fase a maconha e cocaína, sendo que esta em especial (e em maior grau o crack, seu derivado), por causar severa dependência em seus usuários. O STJ, responsável pela uniformização da aplicação do direito infraconstitucional, tem entendido como razoável o aumento de um décimo na pena-base para quantias em torno de 100g de cocaína, como no HC 437972/SP (Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018). Ver também:

No caso, observa-se que o Tribunal de origem, com fundamento o art. 42 da Lei de Drogas, elevou a pena-base em 1 ano, em razão da aferição desfavorável da quantidade e da natureza da droga (120 g de cocaína).

Tendo sido indicados elementos válidos para a majoração da reprimenda básica, uma vez que significativo o quantum e altamente nociva a substâncias apreendida, não se identifica a alegada contrariedade do art. 59 do CP, sobretudo quando tais circunstâncias foram elencadas legalmente como preponderantes, e as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas são de 5 a 15 anos de reclusão.

STJ, HC 431541/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018.

Os elementos existentes nos autos informam que o Tribunal de Justiça de Goiás deu

parcial provimento ao apelo defensivo para declarar extinta a punibilidade pela prescrição em relação ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, mantendo, no mais, a condenação do recorrente à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa se insurge, inicialmente, contra o quantum de aumento da pena-base argumentando ausência de fundamentação para a sua majoração em dois anos acima do mínimo legal.

Sem razão, porquanto as circunstâncias em que ocorreu o delito e a quantidade e variedade do entorpecente apreendido (08 porções de cocaína petrificada pesando no total 55,030g e 27 porções de maconha, com massa bruta total de 6.303,75g) justificam o aumento da pena basilar. Nessa linha: HC n. 430.461/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 16/04/2018 e HC n. 434.195/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma DJe 01/03/2018.

AgRg no AREsp 1347544/GO, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018.

Da leitura atenta dos excertos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem estabeleceu, em decisão suficientemente motivada, as penas-bases acima do mínimo legal, para os delitos de tráfico e de associação para o tráfico, na medida em que destacou a quantidade e a natureza da droga apreendida - 1 porção de cocaína (84,69g) e outras 5 porções da mesma substância (1,93g) - e o fato de o paciente se valer de familiares de detentos para o transporte de entorpecentes.

(...)

Dessa forma, levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos delitos, o deslocamento das pena-base para 7 anos de reclusão e para 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, respectivamente, para os crimes do art. 33 e 35 da Lei de Drogas, é suficiente e adequado à reprovação da conduta delitiva, em razão da quantia e da nocividade dos entorpecentes apreendidos e da conduta social do agente, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

STJ, HC 452708/SP, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018.

(...) as instâncias antecedentes consideraram a quantidade e a variedade de droga apreendida - 50 frasquinhos de cocaína (28,9g) e 45 pedras de crack (6g) - para majorar a pena inicial em 1/6, o que não se mostra desproporcional.

STJ, HC 458961/SP, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23/08/2018, DJe 03/09/2018.

Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da Vigésima Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo/SP à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Eis os termos do decisor, no que interessa:

6.- Passo a fixar a pena, enquadrando a conduta do réu no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. É necessária a fixação da pena-base do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais manifestamente desfavoráveis, conforme autoriza o artigo 59 do Código Penal. Trata-se de 11 porções de cocaína, acondicionadas em plástico transparente, com o peso líquido de 11,0 g e 158 porções de "crack", acondicionadas em papel alumínio, com o peso líquido de 78,3 g, que seriam destinados a um grande número de pessoas desta cidade. Sendo assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em sete anos de reclusão e setecentos dias-multa.

(...)

Não se vislumbra, in casu, manifesto constrangimento ilegal no tocante à exasperação da pena-base, porquanto foram adotados elementos concretos para justificar a dosimetria, não parecendo arbitrário ou desarrazoado o quantum imposto tendo em vista a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas - 11 porções de cocaína (11 g) e 158 porções de crack (78,3 g) (fl. 14) -, a atrair a incidência do art. 42 da Lei n.º 11.343/06.

(...)

devidamente fundamentada a manutenção do regime inicial fechado, com base nas circunstâncias do caso concreto, não há ilegalidade a ser sanada. STJ, HC 326418, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015.

Seguindo este raciocínio, a reprimenda pela maconha deve ser feita em patamar inferior (metade) e a valoração negativa pelo crack em patamar superior (dobro). Nem se alegue a existência de julgados no STJ em que são mantidas decisões com aumentos menores de pena a quantidades maiores de drogas. É preciso ler corretamente a jurisprudência da corte e entender que no julgamento de habeas corpus ou de recurso exclusivo da defesa apenas se verifica se houve excesso contra o réu, inexistindo o refazimento da dosimetria pelos ministros segundo os seus parâmetros (até porque, segundo remansosa jurisprudência da corte, isso implicaria revolvimento do conjunto fático-probatório - "Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena", STJ, HC 462899, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23/10/2018, DJe 05/11/2018). Percebe-se, desta forma, que a valoração aqui indicada não é considerada excessiva pelos tribunais superiores.

Nem se alegue também que há aqui tarifação na dosimetria. Apenas se cumpre a determinação da lei especial de graduar a pena segundo a dimensão da ofensa ao bem jurídico; o que é sempre preferível, pois fixa a sanção privilegiando as condições do fato em detrimento das condições do autor.

Assim, conjugando as drogas apreendidas com as quantidades encontradas, aplico um acréscimo de seis décimos do intervalo nesta fase.

Não cabem também alegações de que o aumento foi excessivo e não considerou as demais circunstâncias judiciais. Ora, por conta da presunção de inocência, inicia-se o cálculo da pena a partir do seu mínimo, partindo da ideia de que as circunstâncias não desabonam a pessoa acusada. Todavia, afastada esta presunção a partir de dados do processo, o aumento é justificado; e é justificado quando supera as tradicionais frações de 1/8 ou 1/6 levando em conta a significativa ofensa à saúde pública. No caso, aumento esse balizado segundo parâmetros consagrados da jurisprudência.

Reconhece-se até que razões de política criminal poderiam diminuir o rigor da sanção caso se provasse certas circunstâncias pessoais da vida da pessoa acusada que indicassem um afastamento social de menor duração como favorável à ressocialização. Todavia, não só não se provou, como a dimensão da ofensa conjugada com a reprovação da conduta pelo direito interno (na Constituição ver, p.ex., os incisos XLIII e LI do art. 5º, inciso II do §1º do art. 144 e art. 243) indicam como recomendáveis e necessárias à prevenção especial a segregação por longo período.

Fixo a pena-base em 11 anos de reclusão e 1.100 dias-multa.

Segunda etapa. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Terceira etapa. Conforme entendimento consolidado do STJ, a quantidade de drogas, de forma isolada, não pode afastar a figura privilegiada do tráfico.

Com grifos nossos:

PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade

ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira.

4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença.

REsp 1887511/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021.

No caso, inexistindo qualquer outro elemento a caracterizar a dedicação da pessoa imputada às atividades criminosas e inexistindo circunstâncias não preponderantes avaliadas negativamente, de rigor a aplicação do privilégio em seu grau máximo.

Considerando o total de pena imposto e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial deverá ser, conforme orientação jurisprudencial, o semiaberto.

Impossível a substituição da sanção corporal por penas restritivas de outros direitos em razão da acentuada culpabilidade evidenciada pelo volume e nocividade das drogas encontradas.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR JONATAS HENRIQUE DA SILVA SANTOS à pena de reclusão, pelo prazo de três anos e oito meses, em regime inicial semiaberto, bem como a 366 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30

(um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, as razões de sua prisão cautelar (fls. 83/89) estão mantidas.

3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

(...)

5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes.

STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

Aliás, a custódia cautelar em casos análogos tem sido mantida pelos tribunais superiores:

3. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado.

4. Na espécie, a custódia cautelar foi mantida para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, caracterizada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos agentes - cocaína (13 pinos), crack (53 pedras) e maconha (72 trouxinhas).

5. Ordem denegada.

STJ, Sexta Turma, HC 375559/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016.

O tempo de prisão preventiva (a pessoa condenada foi presa em 25/08, com reavaliação da prisão em 07/10) não autoriza, por hora, qualquer mudança em seu regime prisional. Todavia, condenado em regime menos gravoso, deverá haver nova expedição de mandado de prisão.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento de todos os valores e bens apreendidos em favor da União Federal, ainda que não se tenha comprovado a sua habitualidade na prática do tráfico, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06, que regulamenta o parágrafo único do art. 243 da Constituição, e sua interpretação dada pelo pleno do STF. Todavia, por serem inservíveis e antieconômicos para a SENAD, determino a destruição ou doação do telefone pessoa móvel Motorola MOTOG31.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06 e Comunicado CG 2225/18, determino a destruição de eventuais amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 17 de novembro de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA